

1503730-36.2021.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação procede. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503730-36.2021.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503730-36.2021.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TCHAI IANOV e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

TCHAI IANOV e MARCIA APARECIDA GAICHI foram denunciados por incursão nos incisos II e IV do parágrafo 4º do art. 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 19h30min, na Avenida Barão de Mauá, 5716, Jardim Canadá, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, mediante fraude, subtraíram, para proveito comum, 3 peças de salame, um quilo de peito de peru, um quilo de muçarela, 24 frascos de desodorante aerossol e 4 pares de chinelos, tudo avaliado em R\$ 466,00 (fl. 32), pertencentes ao Supermercado Lourencini.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fl. 71 e 73) e apresentaram resposta à

acusação.

As testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se os réus.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa insiste no cabimento de proposta de acordo de não persecução penal e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão e do privilégio, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Destaca-se, inicialmente, que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo dos réus, mas ato discricionário do Promotor de Justiça. No mais, diante da recusa do Ministério Público, os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, que insistiu na recusa de oferta do referido acordo (fls.89-95).

Ressalta-se que o acordo de não persecução penal não pode ser imposto pelo Judiciário em caso de recusa do Ministério Público. Neste sentido precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe que: 'Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)'. Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação." (HC 2026314-51.2020.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Júnior, j. 05.04.20). g.n.

"Habeas Corpus. Insurgência quanto à ausência de propositura de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação procede.

Comprovou-se a materialidade pelo boletim de ocorrência (fls. 03-4), relatório de investigação (fls.06-8), auto de reconhecimento pessoal (fls.11-2), auto de avaliação (fl. 32) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogados, em solo policial (fl.13-4) e em juízo (mídia digital), os réus confessaram.

A testemunha Sandra, na fase administrativa (fl.09), disse que: (sic) "trabalhava no caixa do mercado Lourencini e era por volta de 19 horas ou mais, quando registrava a compra de uma mulher, viu que encostou um outro cliente que colocou dois pacotes de papel higiênico e um pacote de fraldas sobre o caixa, que dificultou a visão da depoente, mas percebeu que tinha um carrinho de compras com ele. Em seguida, esse rapaz branco, calvo parcial, magro, alto com 1,80m de altura aproximada, foi ao seu lado e lhe fez a seguinte pergunta 'moça, aqui aceita o aplicativo caixa tem?', respondido que sim, esse rapaz saiu do caixa e a depoente continuou a dar atendimento para finalizar a cobrança das compras daquela cliente, que pagou pela mercadoria e foi embora, mas salienta que não viu o rumo que esse indivíduo tomou após a pergunta. Passados alguns minutos, cerca de 10, o

funcionário Eduardo foi até o caixa e a indagou 'Sandra, você viu o que aconteceu agora no seu caixa?' e lhe apresentou um vídeo, onde mostra a cena de uma mulher passando pelo caixa, com um carrinho de compras, enquanto era distraída pelo indivíduo. Disse a depoente que em nenhum momento avistou essa mulher saindo com o carrinho, pois sua atenção foi distraída e naquele momento só se recordou do indivíduo. Pelo vídeo, a depoente conseguiu ver a mulher como sendo alta, cabelos pretos e amarrados, pele branca, forte, usando roupa larga. Soube a depoente que Eduardo tentou deter o casal no estacionamento, mas não teve êxito porque fugiu num carro".

Em juízo, reiterou a sua versão. Afirmou que o réu Tchai aproximou-se do caixa, fez uma barreira com papel higiênico e fraldas e chamou sua atenção, momento em que a corré Marcia passou com as mercadorias furtadas, por trás da moça que estava atendendo. Pelas câmeras de segurança viram que os acusados saíram correndo pelo estacionamento e entraram em um carro que estava estacionado (mídia digital). A qualificadora do emprego de fraude foi comprovada pela prova oral colhida, uma vez que o réu Tchai utilizou-se de artifícios enganosos, aproximando-se do caixa, fazendo uma barreira com papel higiênico e fraldas e chamando a atenção da funcionária, com intuito de, na verdade, mitigar sua vigilância e possibilitar a passagem da corré Marcia com as mercadorias furtadas. Do mesmo modo, provado o concurso de pessoas.

Ressalta-se que a qualificadora relativa ao emprego de fraude é de natureza subjetiva e, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna incompatível o reconhecimento do benefício previsto no § 2º do art. 155 do CP, ainda que os acusados sejam primários e a res furtiva considerada de pequeno valor (fl.32-R\$ 562,00), considerando-se o salário mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 1.212,00). Neste sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

"No presente caso, embora os recorridos sejam primários e a res furtiva considerada de pequeno valor - porquanto inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 320,00) -, a qualificadora relativa ao emprego de fraude é de natureza subjetiva, razão pela qual não é possível a incidência do benefício previsto no § 2º do art. 155 do CP." (RECURSO ESPECIAL Nº 1.841.048 - MS (2019/0293142-3), RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 18.11.19).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos moldes da orientação jurisprudencial desta Casa, consolidada no enunciado n. 511, é possível a incidência do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, no caso de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. Entretanto, tanto a qualificadora do abuso de confiança como a do emprego de fraude possuem "natureza subjetiva e, por essa razão, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna[m] incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto, independentemente do pequeno valor da res furtiva e da primariedade da agravante" (AgRg no AREsp n. 395.916/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/2/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 462.322/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n. 1.193.932/MG, 1.193.558/MG, 1.193.554/MG e 1.193.194/MG, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC, consignou que "afigura-se absolutamente 'possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º)', máxime se presente qualificadora de ordem objetiva, a primariedade do réu e, também, o pequeno valor da res furtiva". 2. No caso, embora o recorrente seja primário e a res furtiva considerada de pequeno valor - porquanto inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos -, a

qualificadora relativa ao emprego de fraude é de natureza subjetiva, razão pela qual reitero o entendimento de não ser possível a incidência do benefício previsto no § 2º do art. 155 em seu favor. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1578367/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016).

Dentro deste espectro, de rigor a condenação dos réus.

Passo à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, diante da multiplicidade de qualificadoras, sendo que o emprego de fraude foi utilizado para qualificar o crime e o concurso de agentes para exasperar a reprimenda, perfazendo, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Neste sentido:

"(...) O apelante foi beneficiado com a fixação da pena base no piso legal, haja vista a multiplicidade de qualificadoras, sendo que, uma delas poderia ter sido utilizada para qualificar o crime e, as demais, para exasperar a reprimenda básica". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500815-20.2021.8.26.0540, Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j. 16.03.22).

"APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP DESFAVORÁVEIS - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - POSSIBILIDADE DEVIDO À REINCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. A confissão e a delação extrajudicial, amparadas nos depoimentos das testemunhas e nos demais elementos dos autos, formam prova robusta para condenação. Não caracteriza bis in idem a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime do furto duplamente qualificado, e outra como circunstância judicial. Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias do artigo 59 do CP desfavoráveis, o que também justifica a fixação do regime fechado para cumprimento de pena, mormente se o réu é reincidente." (TJ-MS - APR: 10350 MS 2005.010350-7, Relator: Des. Carlos Stephanini, Data de Julgamento: 07/03/2006, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/03/2006)

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo que uma serviu para a tipificação do crime de furto qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável - motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -, não havendo qualquer constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada." (STJ - HC: 202035 SP 2011/0070113-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/06/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2011)

Na segunda fase, diante da atenuante da confissão, as penas retornam aos patamares mínimos, definindo-se as penas em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, ausentes outras causas modificadoras.

O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a sanção corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade

pelo prazo da pena imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária à entidade beneficente a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor de 1 (um) salário mínimo, sem prejuízo da multa já fixada.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus TCHAI IANOV e MARCIA APARECIDA GAICHI, qualificados nos autos, a cumprir pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 10 dias-multa, no unitário mínimo, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma acima especificada, por incursão nos incisos II e IV do parágrafo 4.º do art. 155 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Mauá, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA